

1502710-04.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... que estavam em operação contra o tráfico de drogas neste município de Campo Limpo Paulista, em local já conhecido pelo tráfico de drogas, sendo que já efetuaram outros flagrantes ali; viram o réu parado na calçada, em frente a um bar fechado naquele momento. Abordado, no bolso de sua jaqueta foi localizada uma sacola com drogas (cocaína, crack e maconha) e trinta e nove ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502710-04.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502710-04.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2301062/2021 - DISE-DEL.SEC.JUNDIAI, 21211759 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 179/21/420 - DISE-DEL.SEC.JUNDIAI, 2301062 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS GABRIEL DE ANDRADE

Réu Preso

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

ISAIAS GABRIEL DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto porque, no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Rua Alvorada, nº 255, bairro do Botujuru, nesta cidade e comarca de Campo Limpo Paulista, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em sete porções de cocaína, com peso bruto de 18,27g (dezoito gramas e vinte e sete decigramas), seis porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso bruto de 29,58g (vinte e nove gramas e cinquenta e oito decigramas) e onze pedras de crack,

derivado de cocaína, com peso bruto de 16,59g (dezesesseis gramas e cinquenta e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 19, o laudo de constatação provisória de 35/37 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 63/65 (fls.73/74).

Em audiência de custódia o flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 41/42).

Laudo químico-toxicológico juntado às fls. 64/65.

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 85/86).

Certidão criminal (fls. 90/92)

O réu foi pessoalmente citado (fls. 96) e apresentou resposta escrita (fls. 104/105), por intermédio de advogado nomeado pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 99).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 107.

FA (fls. 119/123).

Em audiência de instrução (fls. 130/131), foram ouvidas duas testemunhas (fls. 127/128) e em seguida o réu foi interrogado (fls. 129). Homologada desistência requerida no tocante à oitiva da testemunha Márcio Henrique Ortolani. Em alegações apresentadas oralmente, o Ministério Público pediu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia (fls. 130/131).

Convertido o julgamento em diligência para apresentação de alegações finais escritas pela Defesa, esta, por sua vez, pugnou pela improcedência, ante a ausência de elementos de prova suficientes para condenação e, subsidiariamente, a fixação das penas no grau mínimo, com a consideração da atenuante da confissão e causa de diminuição de pena; por fim, que a pena privativa de liberdade seja substituída ou ainda que o regime fixado seja o aberto (fls. 132/141).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com vênia ao esforço do combativo advogado, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 30/33), auto de exibição e apreensão as drogas (fls. 19), laudo de constatação (fls. 35/37) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico, que atestou positivo para tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo da Cannabis sativa L, bem como cocaína, em sua forma pura e como substância ativa do crack (fls. 64/65).

Da mesma forma, a autoria é inquestionável.

A testemunha, investigador de polícia, Luis Ricardo Luan dos Santos, declarou, em síntese, que estavam em operação contra o tráfico de drogas neste município de Campo Limpo Paulista, em local já conhecido pelo tráfico de drogas, sendo que já efetuaram outros flagrantes ali; viram o réu parado na calçada, em frente a um bar fechado naquele momento. Abordado, no bolso de sua jaqueta foi localizada uma sacola com drogas (cocaína, crack e maconha) e trinta e nove reais em cédulas fracionadas. Questionado, o acusado inicialmente negou o tráfico, mas em seguida acabou por confessar o crime. Não conhecia o réu até então. No local o réu estava sozinho.

Cícero Alves de Araújo, também policial civil, declarou que na data dos fatos, vieram para Campo Limpo Paulista, mais precisamente para o bairro do Botujuru, visando coibir o tráfico de drogas, em local já conhecido, ao lado de um bar; viram o réu (sozinho) em atitude suspeita e resolveram aborda-lo. Na posse do réu, localizaram em uma sacolinha, porções de cocaína, crack e maconha e trinta e nove reais em notas fracionadas. Indagado, de início o acusado negou o tráfico, mas em seguida acabou confessando o tráfico. Não conhecia o réu.

Logo, restou devidamente demonstrado que o réu estava traficando no local, ou seja, não se trata de condenação tão somente com base em confissão, mas sim que esta foi ratificada pela prova testemunhal.

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública: "O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda: "Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Sem o destaque no original.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime, declarando que estava no local traficando por necessidade, visto que tem dois filhos para criar e o dinheiro que ganhava em um Lava Car não era suficiente. Sua filha está sob sua guarda; o outro está com a avó materna. Aceitou o convite de terceiro para traficar para comprar leite para o filho. Já foi processado por tráfico, mas foi absolvido.

Portanto, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime, a responsabilização penal se impõe, na ausência de excludentes, visto que, o ônus de provar o alegado estado de necessidade pertencia à Defesa, que dele não se desincumbiu.

Outrossim, ainda que o réu tenha de fato filhos, o que não foi provado nos autos, segundo o que ele mesmo depôs em audiência, um deles está com a avó materna e a filha está com a mãe.

Passo a fixar a pena.

Na primeira fase de fixação das penas, em atenção às diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas e ainda personalidade e conduta social do agente), preponderantes sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, visto que o delito ora em análise é tipificado em lei especial, aumento as penas em um sexto, em razão da quantidade e diversidade de drogas encontradas, notadamente cocaína e crack, as quais atingem o bem jurídico de forma mais severa (elevada potencialidade lesiva), elevando-a para cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, constato a presença da circunstância atenuante da confissão, razão pela qual trago as penas aos patamares mínimos, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na terceira fase, tendo em vista que o réu preenche os requisitos descritos no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (visto ser tecnicamente primário e ostentar bons antecedentes), reduzo a pena aplicada em 2/3, resultando em um ano e oito meses de

reclusão e pagamento de cento e sessenta e oito dias-multa. Pontuo que a quantidade e diversidade de drogas, assim como o maior potencial lesivo do crack e da cocaína já foram usados como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da fixação das penas (ressaltando que o art. 42 da Lei de Drogas prepondera sobre o art. 59 do CP), não podendo ser reutilizados sob pena de "bis in idem".

O valor unitário deverá ser o mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal que a Justiça Pública move contra ISAIAS GABRIEL DE ANDRADE, já qualificado nos autos, para, com base no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LO às penas de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e oito dias-multa, no valor unitário mínimo.

Com vênia a entendimentos em contrário, entendo inaplicável a Lei nº 12.736/12; isto porque o Magistrado, no momento da prolação da sentença, não possui elementos para a aplicação de eventual detração penal e progressão de regime penitenciário. Como cediço, não basta o mero abatimento na pena final do tempo de cumprimento de prisão cautelar; há que se ter em conta as imprescindíveis informações do estabelecimento penal quanto ao comportamento do acusado e folha de antecedentes. Por sinal, até mesmo a constitucionalidade da lei há que ser analisada de forma mais apurada, visto que, salvo melhor juízo, a alteração normativa ignora o princípio do Juiz Natural e até mesmo da individualização da pena.

Neste sentido, eis recente acórdão do TJSP: "Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP. Apelação nº 0012399-50.2003.8.26.0198. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Grassi Neto. Data do julgamento: 18/08/2016. Data de registro: 01/09/2016). Deixo de aplicar pena alternativa ou suspensão condicional da pena, em razão da proibição do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Nos termos da Lei nº 8.072/90, em especial das circunstâncias desfavoráveis do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e atento ao fato de que o tráfico de drogas fomenta uma série de outros delitos tais como homicídios, roubos, furtos etc., que tem destruído milhares de famílias e ainda que atinge seriamente o Sistema de Saúde do país que, progressivamente vem aumentando seus gastos com internações e tratamento de dependentes químicos, cumprirá o réu a pena privativa de liberdade inicialmente no regime FECHADO. Destaco que nenhum dos respeitáveis entendimentos do STJ e do STF foi sedimentado em Súmula Vinculante.

No sentido da correção de fixação de regime fechado para os crimes de tráfico de drogas: "O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu

tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto." (TSJP. Apelação nº 0010186-03.2015.8.26.0602. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 06/07/2016. Data de registro: 12/07/2016).

E ainda, convém destacar trecho do voto do Eminentíssimo Desembargador DAMIÃO COGAN, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da apelação nº 0000779-16.2016.8.26.0544, Quinta Câmara de Direito Criminal, J. em 21/09/2017: "O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancrios da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios."

Outrossim, com a mais necessária vênua, reitero que a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução nº 5 do Senado Federal, não possui força vinculante e muito menos afastou do Juiz a análise das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, a Colenda Quinta Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu recentemente:

"(...) a respeitabilíssima decisão do E. Supremo Tribunal Federal mencionada pela impetrante foi declarada incidentalmente. E, de qualquer forma, o reconhecimento do que se denominou "tráfico privilegiado" (e nem parece ser o caso) não obriga o estabelecimento desse ou daquele regime, o que vai ser fixado consoante as condições específicas do caso. De mais a mais, impossível apreciar, nesta fase, se o paciente preenche os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ainda que a conduta de tráfico privilegiado não fosse considerada hedionda, observo e insisto, isso não impediria a prisão preventiva ou garantiria ao réu o direito ao regime aberto. Restou demonstrado, conforme já consignado, a necessidade da prisão cautelar do paciente, diante da gravidade em concreto da conduta. Colocar o paciente, intimamente ligado ao tráfico em larga escala, reafirmo, coloca em risco concreto toda a sociedade" (TJSP. Habeas Corpus nº 2154869-28.2016.8.26.0000, Indaiatuba, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 01/09.2016).

No mesmo sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

"... TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59 do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro Ericson Marinho" (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).

O réu permaneceu preso durante o procedimento penal, com a conversão da detenção em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos requisitos e hipóteses autorizadoras de tal custódia, de tal sorte que não poderá apelar em liberdade, pois não houve qualquer alteração fática de tal quadro.

Destaco que a decisão por maioria de votos do Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 104339, quanto à inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei nº 11.343/2006 apenas se refere à regra que proíbe a liberdade provisória; ou seja, não importa na vedação da decretação da prisão preventiva, desde que presente seus requisitos e pressupostos, o que é o caso sub judice.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário.

Quanto às custas processuais, condeno o réu no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ele seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do art. 63, §1º e 64 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda em favor do Estado da quantia apreendida em poder do acusado.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Oportunamente, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários ao advogado que patrocinou a defesa do acusado, nos termos da tabela do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública.

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Procedam-se as devidas anotações, comunicações e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA